

1500801-82.2021.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... um dos responsáveis pela prática do crime de tráfico.

Ademais, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (915g de cocaína), a forma em que se encontravam (duas grandes porções), bem como a apreensão de "ependorfs", não deixam dúvidas de que se tratava de entorpecente destinado ao tráfico. Nesse sentido:

Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, forma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Varação

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500801-82.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500801-82.2021.8.26.0363

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2170509/2021 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 18677403 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO,

2942/21/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2170509 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2942/21/930

- DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR RAFAEL LEITE DIVINO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

IGOR RAFAEL LEITE DIVINO, KAUAN WILLIAN MALVEZZI MACHADO e RAFAEL GUILHERME DOS SANTOS ALBANO SILVERIO, todos qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local ali

descritas, nas imediações de praça pública e de uma quadra poliesportiva, agindo em conjunto, com unidade de desígnios e divisão de atos executórios, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes causadoras de dependência química, consistentes em 02 (duas) grandes porções de cocaína, com peso aproximado de 915 gramas.

A denúncia foi recebida em 28 de julho de 2021 (fls. 112). Os réus foram citados (fls. 160, 162 e 164) e apresentaram resposta à acusação (fls. 141/143).

Na audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e duas testemunhas da defesa. Ao final, realizou-se o interrogatório dos acusados (fls. 234 e 238).

O Ministério Público, por meio de sua representante, requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, nos exatos termos da denúncia. Em relação à aplicação da pena, opinou pela fixação acima do mínimo legal, visto a elevada quantidade e nocividade das drogas apreendidas. Na segunda fase, pugnou pela consideração da reincidência em relação ao acusado Kauan. Ressaltou que os acusados Igor e Rafael não podem ser beneficiados pela atenuante da confissão espontânea, vez que inocentaram o acusado Kauan da prática do delito. Ademais, pleiteou, na terceira fase, a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06 e a não concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da mesma lei. Encerrou, requerendo o regime inicial fechado e manifestando a sua contrariedade à conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (mídia digital).

A defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição dos acusados, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena em seu mínimo legal, bem como o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em relação aos acusados Igor e Rafael, os quais também requereu que fossem beneficiados com a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com redução em grau máximo. Ao final, pleiteou o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, e a fixação de regime aberto, com a substituição da pena privativa liberdade por restritivas de direitos (fls. 244/252).

É o relatório

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova oral e pelas seguintes peças do inquérito policial: autos de prisão em flagrante (fls. 02/09), exibição e apreensão (fls. 10) e constatação preliminar (fls. 11/12), boletim de ocorrência (fls. 16/18), laudo do local do crime (fls. 134/139), exame de objeto apreendido (fls. 125/127) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 128/130 e 131/133).

Os acusados Igor e Rafael, ao serem interrogados em juízo, confessaram a prática do delito, declarando que ambos estavam guardando a droga para uma terceira pessoa em troca de R\$ 500,00. Negaram, entretanto, a concorrência de Kauan para o delito.

Kauan, por sua vez, negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia, dizendo que não tinha ciência de que havia drogas na casa de Rafael e que havia ido ali desse somente para comer uma pizza, porque eram amigos de infância.

Como veremos a seguir, a confissão dos réus Igor e Rafael encontra respaldo no conjunto probatório, ao passo que a negativa de Kauan permanece completamente isolada nos autos.

O Policial Civil Jairo Marcos Pereira Passos relatou que havia uma investigação em andamento para apuração do envolvimento de Kauan com o tráfico de drogas e que as diligências realizadas revelaram que ele e Rafael preparavam e acondicionavam drogas na residência desse último. Relatou, ainda, que ingressou no imóvel e surpreendeu os réus na cozinha, embalando as porções de droga. Encerrou, dizendo que apreendeu duas porções grandes de cocaína e pinos plásticos vazios (fls. 04 e mídia digital).

Nesse mesmo sentido foram as declarações do Policial Civil Carlos Juliano Martins (fls. 06 e mídia digital).

As testemunhas de defesa, Márcia Benedita Santos de Souza e Raquel de Souza, atestaram a boa conduta social do acusado Rafael, dizendo que ele possui emprego com registro na carteira de trabalho e que, apesar de ele ser usuário de maconha, jamais ouviram dizer que fosse traficante de drogas.

Importante salientar que o depoimento dos policiais civis que participaram da diligência são válidos e suficientes para embasar uma sentença condenatória, mormente pelo fato de não haver nenhum indício de que faltaram com a verdade para legitimar suas ações ou para prejudicar o acusado.

Aliás, a orientação jurisprudencial é pacífica e torrencial no sentido de dar total valor aos depoimentos prestados por policiais. A título exemplificativo, temos o seguinte precedente jurisprudencial:

“PROVA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. VALIDADE. Como reiteradamente tem-se decidido, o depoimento do policial é válido e eficiente para estear veredicto condenatório. Afinal, em tese, trata-se de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade. Não há porque, antecipadamente, vedá-las, pois as hipóteses de impedimento ou suspeição estão elencadas na lei processual de forma taxativa. Cumpre a Defesa provar com segurança que tais depoimentos são viciados e fruto de sentimento escuso para prejudicar o réu. Isto não aconteceu no caso em julgamento (...)” (Apelação Crime nº 70011511292, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, relator: Sylvio Baptista, julgado em 07/07/2005).

Nesse sentido, temos ainda o seguinte julgado:

“os policiais não estão impedidos de testemunhar e seus depoimentos não de ser recebidos com o mesmo valor das testemunhas não policiais. Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente de polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isso mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que a do cidadão comum.” (in “Jurisprudência Penal e Processual Penal”, AZEVEDO FRANCESCHINI, VOL. 8, pág. 386).

As testemunhas de defesa, por outro lado, limitaram-se a atestar a boa conduta social do acusado Rafael, sem nada apresentar de relevante para o desfecho da ação penal.

A prova acusatória, portanto, demonstrou satisfatoriamente a responsabilidade penal dos réus, de modo que não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa.

Apesar de os réus Igor e Rafael terem dito que Kauan não tinha ciência da droga, a prova testemunhal revela o contrário. Além disso, os antecedentes de Kauan demonstram que ele já foi condenado anteriormente por crime da mesma espécie.

Da análise das provas conclui-se que a condenação dos réus é medida de rigor, pois, além da confissão de Rafael e Igor, os policiais civis deixaram claro que a investigação realizada previamente apontava o Kauan como um dos responsáveis pela prática do crime de tráfico.

Ademais, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (915g de cocaína), a forma em que se encontravam (duas grandes porções), bem como a apreensão de “ependorfs”, não deixam dúvidas de que se tratava de entorpecente destinado ao tráfico. Nesse sentido:

Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio Desclassificação para uso inadmissível.”(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige a prática de ato típico de comércio, bastando que o agente traga consigo ou tenha em depósito a substância entorpecente.

O artigo 33 da Lei nº 11.343/06 consiste em um tipo misto alternativo, que tipifica as condutas de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar e entregar a consumo substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Por outro lado, não obstante a natureza objetiva da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06, essa não deve incidir no caso em tela, pois a

preparação da droga não estava ocorrendo à vista dos frequentadores dos locais descritos no laudo pericial, já que os réus encontravam-se no interior de sua residência e não há nenhuma informação nos autos de que a droga era exposta à venda naquele local.

Assim, em razão da clandestinidade da conduta ilícita e da ausência de espectadores, não há como argumentar que houve, nem mesmo potencialmente, maior difusão da toxicomania ou exposição de pessoas à narcotraficância, de modo que a rejeição da causa de aumento consiste em medida de rigor.

Mutatis mutandis, temos o seguinte julgado que demonstra que, para a incidência da majorante, é necessário que haja circulação e aglomeração de pessoas:

Ementa Oficial: RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento.

2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância.

3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

Nesse sentido, decidiu-se, recentemente, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes. Notícias transmitidas aos policiais civis sobre a atuação do réu no narcotráfico. Delação anônima que apontava uma entrega que seria realizada pelo acusado. Após campana, policiais civis visualizaram o réu desembarcando de um veículo, com uma sacola nas mãos. Apreensão de 8 tabletes de maconha em poder dele. O restante da droga, consistente em 40 porções de maconha com peso de 19.685 gramas (mais de 19 quilos), foi apreendido na residência do réu, no interior de uma caixa de papelão, depositada na sala. Insurgência defensiva.

Pleito de reconhecimento das majorantes constantes do artigo 40, inciso III e VI, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Local do flagrante consistente em imóvel habitado pelo acusado. Ausência de prova de que constituiu residência para se favorecer das instituições elencadas [grifo nosso]. Envolvimento de menores não comprovado. Insurgência defensiva. Pretensão de absolvição, com fulcro na insuficiência probatória. Inviabilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Confissão do apelante. Condenação lastreada em sólidos elementos. Réu possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Atenuante da confissão. Penas mantidas. Regime inicial fechado. Negado provimento aos apelos (Apelação 1500369-97.2020 Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara, p. 12 de junho de 2021).

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime e a responsabilidade criminal dos acusados, passo a dosar a pena a ser imposta.

I- Dos acusados Igor e Rafael.

Verifico que os réus são primários e não possuem maus antecedentes (fls. 151/152 e 155/156). Nada há de relevante também quanto às demais circunstâncias, pois a sua

culpabilidade, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as consequências, circunstâncias e motivos do delito foram aqueles próprios à espécie. Ademais, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social. Por outro lado, foi apreendida uma grande quantidade de drogas com alto grau de nocividade (915 gramas de cocaína), o que enseja a exasperação da pena-base.

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em razão da confissão espontânea e da menoridade penal, reduzo a pena de 1/6 (um sexto), estabilizando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por serem os réus primários e possuidores de bons antecedentes, bem como por não haver qualquer prova de que eles se dedicavam a atividades criminosas ou integravam organização criminosa, reduzo a pena, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, de dois terços (2/3), para que a pena seja estabilizada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, tornando-a definitiva nesse montante, ante a inexistência de outras circunstâncias ou causas capazes de influir em seu cômputo.

II- Do acusado Kauan.

Verifico que o réu é reincidente (fls. 151/152), entretanto tal condenação será considerada na próxima fase de dosimetria, para não caracterizar bis in idem. Nada há de relevante também quanto às demais circunstâncias judiciais, pois a sua culpabilidade, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as consequências, circunstâncias e motivos do delito foram aqueles próprios à espécie. Ademais, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social. Por outro lado, foi apreendida uma grande quantidade de drogas com alto grau de nocividade (915 gramas de cocaína), o que enseja a exasperação da pena-base.

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, ou seja, em 06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em virtude da reincidência gerada pela condenação definitiva no processo nº 1500459-75.2019 da 4ª Vara de Mogi Mirim (fls. 149), cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/04/2021, aumento a pena em 1/6, para estabilizá-la em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em virtude da ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de influir em seu cômputo.

Consigno, por fim, que o acusado não faz jus ao benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, por ser reincidente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move contra IGOR RAFAEL LEITE DIVINO, RAFAEL GUILHERME DOS SANTOS ALBANO SILVERIO e KAUAN WILLIAN MALVEZZI MACHADO, para condenar os dois primeiros a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como para condenar o terceiro a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente 700 (setecentos) dias-multa, por infração aos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. Apesar de reconhecida, incidentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade dos artigos 33, § 4º, e 44 da Lei 11.343/06, no tocante à proibição de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade dos réus, por entender que tal medida é insuficiente como forma de punição e ressocialização, principalmente porque eles não comprovaram que possuíam atividade lícita e não demonstraram que estavam aptos à reintegração na sociedade. Como o réus Igor e Rafael praticaram crime de tráfico privilegiado, que, segundo

entendimento do STF, ao qual me filio, não se trata de crime equiparado a hediondo, não há obrigatoriedade de fixação do regime fechado. Considerando que são favoráveis as condições pessoais de ambos, deveria ser fixado o regime inicial semiaberto, porém, como eles permaneceram presos preventivamente por tempo superior a 16% da pena, com fulcro no artigo 387, § 2º, do CPP, fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pelo regime de pena aplicado aos réus supracitados, concedo-lhes o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Quanto ao réu Kauan, com fulcro no §1º do art. 2º da Lei 8.072/90 e no artigo 33 do Código Penal, fixo, para cumprimento inicial da pena, o REGIME FECHADO.

Tendo em vista que ainda continuam vigentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de lhe conceder o direito de apelar em liberdade. Recomendem-no na prisão em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os seus nomes no rol dos culpados.

Custas "ex lege".

P. I. C

Mogi Mirim, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA